

1501346-26.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... os Guardas. O local é ponto de tráfico. Correu e os traficantes também correram antes da abordagem. Portanto, Excelência, verifica-se que o acusado nega a prática do tráfico de drogas, sendo que sua negativa deve ser considerada um elemento probatório, afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais evidências ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501346-26.2021.8.26.0599 - Controle nº 2021/000989

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2234820/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 19909825 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2349/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2234820 - 02º D.P. PIRACICABA, 2349/21/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROBERT DOMINGUES MOREIRA

Réu Preso

Aos 01 de fevereiro de 2022, às 14:30h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 em razão da pandemia do coronavírus, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dr. ANTONIO CARLOS PEREZ ANTUNES DA SILVA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: ROBERT DOMINGUES MOREIRA - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC PEDRO CARLOS GIRHÃO - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC JOEL VASCONCELOS DE LIMA - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunha GC PEDRO CARLOS GIRHÃO.

Dada a palavra ao Dr. Promotor, por ele foi dito que desistia da oitiva da testemunha GC JOEL VASCONCELOS DE LIMA, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha GC JOEL VASCONCELOS DE LIMA, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Após, o réu ROBERT DOMINGUES MOREIRA foi devidamente interrogado. O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ. A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito o seguinte: "O réu ROBERT DOMINGUES MOREIRA foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33 da Lei de Drogas. De acordo com a denúncia, no dia 27 de agosto de 2021, por volta de 17 horas, na rua Garça, altura do nº 209, bairro Jardim Itapuã, nesta cidade e comarca, ROBERT DOMINGUES MOREIRA, qualificado a fls. 4/5, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 53 eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 74,3g; e 2 eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 9,6g (cf. laudo de constatação de fls. 13), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O processo teve trâmite regular, conforme se observa a fls. 106, 110/113 e 118/121. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de AEA de fls. 9/11; foto de fls. 10; laudo de constatação de fls. 13/14; laudo do exame químico-toxicológico de fls. 97/99. A autoria também foi determinada na prova oral coligida. Os GMs contaram, em uníssono, que, durante o patrulhamento surpreenderam o denunciado em conhecido ponto de tráfico de drogas. Notando a presença da patrulha, o indiciado empreendeu fuga e, no trajeto, dispensou a sacola que portava e continha 53 porções de cocaína, posteriormente recolhida. ROBERT foi alcançado e submetido à busca pessoal. Resultou dessa providência o encontro em seu poder e apreensão de outras duas porções de cocaína, idênticas às existentes na sacola já mencionada. No panorama dos autos, a condenação é de rigor. A contradição entre a versão do réu e a dos GMs resolve-se em favor destes. De fato, nossas Cortes de Justiça avalizam os depoimentos de policiais, forte no entendimento de que seria um contrassenso acometê-los da difícil missão de atuar na prevenção e repressão de crimes para, em seguida, negar validade a seus relatos, justamente quando prestam conta em Juízo de seu sensível trabalho (Sobre a validade da palavra dos policiais, cf. TJ-SP - APL: 0000162-52.2013.8.26.0547, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 06/11/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/11/2014). Assim, a condenação é de rigor. No tocante à aplicação da pena, observa-se que o réu é reincidente (fls. 89 e ss.), razão pela qual não faz jus à causa de diminuição prevista no parágrafo 4º., do art. 33, da Lei Antidrogas. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende, EM SEDE PRELIMINAR, que as provas obtidas nos autos, em especial as substâncias entorpecentes encontradas pelos Guardas Municipais são ilícitas, eis que a abordagem e a prisão do acusado decorreu de autoridades incompetentes. Com efeito, de acordo com a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 144, § 8º, os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, sendo o referido dispositivo reproduzido de forma idêntica na Constituição do Estado de São Paulo. Portanto, de acordo com as referidas disposições, vislumbra-se que a atual ordem jurídica contempla quais são as específicas atribuições da Guarda Municipal, órgão ao qual incumbe a defesa e proteção dos bens, serviços e instalações em âmbito municipal. Ou seja, as Guardas Municipais não têm status de polícia ostensiva, função esta que cabe a Polícia Militar do Estado de São Paulo. No caso em tela, verifica-se que houve flagrante invasão de competência material, pois a Guarda Municipal atuou como se fosse polícia ostensiva. Nesse aspecto, cumpre mencionar que os Guardas, de forma ilegal, abordaram o acusado sem que qualquer situação de flagrante delito estivesse visível, ainda que fossem autoridades incompetentes para tanto. Essa função, todavia, não incumbe aos Guardas Municipais, mas à Polícia Militar. Na realidade, os Guardas Municipais, diante do fato, deveriam ter acionado o órgão

competente para atender à ocorrência. Na atual ordem jurídica, existe a polícia ostensiva, representada pela Militar, e a polícia judiciária, representada pela Civil. Assim, os Guardas jamais poderiam ter atuado como se possuíssem aptidão para tanto. Há, no caso em comento, evidente invasão de competência administrativa, de índole constitucional, o que enseja a ilegalidade do ato (prisão em flagrante) e de todas as provas carreadas aos autos, visto que elas são provenientes, todas, de atos dos aludidos Guardas Municipais que atuaram como polícia ostensiva, em flagrante desrespeito às suas atribuições constitucionais. Neste sentido, já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Ação Penal - Desarmamento - Guarda Municipal - Ação de polícia ostensiva - Ilegalidade - Apelo provido para absolver o acusado." (TJSP, ACri nº 990.09.226504-0 - 2ª câmara de direito criminal - origem: Piracicaba/SP, julg. 1º/02/10); "Apelação Criminal Tráfico de entorpecentes - Prisão dos réus efetuada por Guardas Municipais - Afirmação dos servidores da realização de campana para confirmar o crime - ilegalidade da ação reconhecida - Admissão, no caso presente, da existência de prova que contamina a ação penal Apelo provido para absolver os réus." (TJSP, ACri nº 0032340-54.2011.8.26.0602 - 2ª Câmara de Direito Criminal - origem: Sorocaba/SP, julg. 12/11/2012). Inclusive, nas palavras do Ilustre Desembargador relator da Apelação Criminal nº 0032340-54.2011.8.26.0602, cuja ementa se encontra acima transcrita e que teve origem na Comarca de Sorocaba/SP, onde também é usual que a Guarda Municipal exerça as tarefas da polícia ostensiva, defendeu, com grande propriedade, o Dr. Almeida Sampaio: "Fica delineado, de maneira bastante evidente, portanto, que, dentro da divisão das atribuições das Polícias, somente à Militar é outorgado constitucionalmente o poder de exercer o policiamento ostensivo, cabendo tão-somente à Guarda Municipal a proteção de seus bens, serviços e instalações". E ainda: "Em razão da Constituição de 1988, todos os entendimentos jurisprudenciais e a legislação que não se coadunem com a norma perderam sua validade. Enquanto não ocorrer alteração dos dispositivos acima transcritos, fica rejeitada a validade da ação de Guarda Municipal que, em ação de policiamento ostensivo, efetua diligências para prender eventual traficante.". Por fim, é cediço que qualquer pessoa do povo pode efetuar a prisão em flagrante e, por isso, em tese, a Guarda Municipal também teria esse poder. Contudo, o que não é permitido é que uma Instituição que tem por função a proteção do patrimônio público se utilize de um poder que não possui e atenda ocorrências, realize investigações e efetue abordagens, a fim de efetuar uma prisão em flagrante. Todavia, se superada a preliminar, QUANTO AO MÉRITO, as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao denunciado. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Pedro, GCM, declarou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Visualizaram um indivíduo parado com uma sacola na mão. Ao ver a viatura, ele saiu correndo e jogou a sacola no chão. Conseguiram abordar o réu e, em revista pessoal, encontraram com ele duas porções de cocaína. Ao observarem a sacola que ele jogou, encontraram o restante do entorpecente, que era idêntico àquele encontrado com o réu. Não conhecia o acusado antes dos fatos. O réu, em interrogatório, declarou que pegou R\$ 45,00 em casa depois que chegou do trabalho e foi até a biqueira. É usuário de drogas e comprou 04 porções de maconha, 02 pinos de cocaína e 01 pedra de crack. Quando a viatura chegou, todo mundo saiu correndo. Os Guardas o abordaram e perguntaram se ele estava com drogas. Disse a eles que estava com entorpecente e os Guardas o colocaram na viatura e o levaram até a Delegacia. Não estava com nenhuma sacola e nada sabe sobre essas drogas. Não conhecia os Guardas. O local é ponto de tráfico. Correu e os traficantes também correram antes da abordagem. Portanto, Excelência, verifica-se que o acusado nega a prática do tráfico de drogas, sendo que sua negativa deve ser considerada um elemento probatório, afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais evidências dos autos. Isso porque, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Guardas Municipais responsáveis pela prisão do acusado, as quais, todavia, devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar,

neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança patrimonial do Município ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem em Juízo a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras de Policiais ou outros agentes de segurança como fundamento para uma condenação: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger." (TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito do depoimento dos Guardas, não existiam sequer denúncias prévias apontando o acusado como o responsável pelo tráfico de drogas na região e não foram avistadas condutas prévias que indicassem o envolvimento do acusado no tráfico de entorpecentes (p. ex., recebimento de dinheiro, entrega de objetos, etc.), além de não terem sido apresentados outros indivíduos como possíveis compradores das drogas e/ou testemunhas presenciais dos fatos. Ressalta-se, também, que grande parte dos entorpecentes, na realidade, não foram localizados sob a posse direta do réu, mas em um local aberto, de livre acesso a qualquer indivíduo. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Portanto, diante das provas produzidas, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [15:11] Rafael Bresciani Marracini Entretanto, na hipótese deste E. Juízo afastar o pleito absolutório, requer-se, ao menos, diante das declarações do acusado em seu interrogatório, a DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO

DE ENTORPECENTES PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. Isso porque, com a devida vênia, há de se reconhecer que não há nos autos indícios de que o acusado fosse comercializar as drogas apreendidas, sendo que, reitere-se, não foi verificado qualquer ato efetivo de mercancia dos entorpecentes. Assim, no máximo, o réu poderia ser responsabilizado por portar drogas para fins de consumo pessoal, pois não foi demonstrado cabalmente o intuito lucrativo, não bastando a simples apreensão do entorpecente em poder do acusado para se justificar uma condenação por tráfico. Vale observar, ainda, que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder do réu nada diz quanto à sua destinação, eis que a quantidade necessária para a satisfação de um usuário é completamente variável. Para a configuração do crime de tráfico, não basta a simples apreensão da droga, sendo imprescindível a aferição de prova cabal da finalidade de mercancia dos entorpecentes por parte do réu, o que não foi o caso. Todavia, caso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, MESMO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. Isso porque, ainda que considerado reincidente, vale lembrar que a Lei de Drogas, ao fixar como pena mínima, para o

delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, a causa de diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para primários, acaba por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que ele integre organização criminosa), é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no patamar de 2/3, implicando a sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela ausência de aplicação da causa de diminuição, uma pena de 5 (cinco) anos. O peso da reincidência, portanto, é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 (um terço) da pena, sendo 2/3 (dois terços) aplicados em função da reincidência. Essa desproporção também é inconstitucional porque atribui, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência implica a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (ou seja, em face de seus antecedentes) e não em função do ato por ele praticado. Como afirma Muñoz Conde: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFE, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo Juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência.” (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Por fim, nem se diga da impropriedade de se afastar uma regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas ou exortações políticas. Mais ainda: trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao eu julgamento, por força do disposto no §1º do art. 5º, da Constituição (“O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos”, in Direitos Humanos – Visões Contemporâneas, edição de Associação Juízes para a Democracia, 2001). Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, sendo que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao acusado, ressaltando-se que a sua vida pregressa deve ser valorada somente na segunda fase, a fim de se evitar eventual bis in idem com eventual agravante da reincidência; (ii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iii) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ; (iv) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato

concreto que autorize, neste momento processual, a manutenção de sua prisão preventiva".

A seguir, pela MM^a. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

ROBERT DOMINGUES MOREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de agosto de 2021, por volta das 17 horas, na Rua Garça, altura do nº 209, bairro Jardim Itapuã, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 53 "eppendorfs" contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 74,3g, e 2 "eppendorfs" contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 9,6g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que guardas civis se depararam com ROBERT em conhecido ponto de tráfico de drogas. Notando a presença da patrulha, o acusado empreendeu fuga e, no trajeto, dispensou a sacola que portava e continha 53 porções de cocaína, posteriormente recolhida. ROBERT foi alcançado e submetido à busca pessoal.

Resultou dessa providência o encontro em seu poder e apreensão de outras duas porções de cocaína, idênticas às existentes na sacola já mencionada.

O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 106) e apresentou defesa preliminar (fls. 110/113), seguindo-se a decisão de fls. 118/121, que recebeu a denúncia.

Designada audiência, foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu.

As partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do acusado.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/11 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 97/99, que trouxe resultado positivo para cocaína.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu fez uso do direito de permanecer em silêncio (fls. 04).

Em juízo, negou a prática do crime. Afirmou que trabalhava de vez em quando como servente com seu cunhado e recebia R\$ 80,00. Disse que, no dia dos fatos, tinha R\$ 45,00 em seu poder, decorrentes do seu trabalho. Asseverou que foi até o ponto de tráfico e adquiriu quatro porções de maconha, duas de cocaína e uma pedra. Então, a viatura entrou na rua, momento em que os moleques que estavam vendendo correram e ele também. Declarou que foi abordado e falou para os policiais o que tinha consigo. Porém, os policiais o colocaram na viatura e o levaram para a Delegacia. A prova produzida, porém, é maciça e incriminadora.

Com efeito, o guarda municipal Pedro Carlos relatou que estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e, perto de uma escada, avistaram o réu parado com uma sacolinha na mão. Ao avistar a viatura, ele desceu correndo a escada e, quando viu que seria abordado, dispensou a sacola. Disse que, na sacola, havia 53 porções que aparentavam ser de cocaína e, com o réu, outras duas porções idênticas às que estavam na sacola. Informou que o réu disse que iria ficar em silêncio.

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal Joel, ouvido a fls. 03.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem guardas municipais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial"

(RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de guardas municipais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes.

Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Por fim, não houve qualquer ilegalidade na conduta dos guardas municipais, já que, conforme dispõe a lei, qualquer do povo pode efetuar prisão em flagrante delito (art. 301 do Código de Processo Penal). Aliás, seria absurdo imaginar-se que os guardas municipais, informados da prática criminosa, não pudessem tomar providências para fazer cessar a infração, ficando, passivamente, no aguardo da chegada de policiais civis ou militares (cf. Apelação nº 0019493-07.2010.8.26.0068, Rel. Des. CESAR MECCHI MORALES, j. 16.12.14).

Enfim, o fato de os guardas terem apreendido duas porções de cocaína em poder do réu e uma sacola contendo outras 53 porções da mesma droga, que ele dispensou no chão, durante a tentativa de fuga para evitar a abordagem, conduz à certeza quanto à autoria.

Prosseguindo, a quantidade do entorpecente apreendida e a forma como estava acondicionado, aliados ao local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, deixam evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.” (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido.” (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, cabendo anotar que, para sua configuração, não se exige qualquer ato de venda, bastando, como no caso em tela, que o agente traga consigo a substância entorpecente.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, observo que o réu é duplamente reincidente (autos nº 1500659-54.2018 e 0016435-98.2016, ambos da 1ª Vara Criminal local - fls. 89/91). Entretanto, esse fato somente pode ser considerado na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se bis in idem. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, em seu valor mínimo legal.

Na segunda fase da fixação da pena, em razão da reincidência, aumento a pena de um quinto, resultando seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, no valor mínimo legal.

Inexistem causas de aumento e, por ser o réu reincidente, não faz jus à redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, em razão da reincidência e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

A fixação do regime inicial fechado está em consonância com diretriz fixada na própria Constituição Federal, que estabeleceu a necessidade de se conferir tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º,

inciso XLIII).

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a qual não pode ser tornada insubsistente, sobretudo em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça: "Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu ROBERT DOMINGUES MOREIRA, qualificado nos autos, à pena de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, fixado o regime inicial fechado e vedado o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias. Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

2) Recebo o recurso interposto.

3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.

4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.

6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 31/01/2034.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo

JUÍZA DE DIREITO
[Assinado eletronicamente]